

1501407-86.2020.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcel Nai Kai Lee

Comarca: Campo Limpo Paulista

Foro: Foro de Campo Limpo Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... de regime fechado para os crimes de tráfico de drogas: "O regime inicial de cumprimento de pena para os crimes de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campo Limpo Paulista

Foro de Campo Limpo Paulista

2ª Vara

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 550, Campo Limpo Paulista-SP - cep 13230-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501407-86.2020.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501407-86.2020.8.26.0544

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2162820/2020 - DEL.POL.CAMPO LIMPO PAULISTA, 12245814 - DEL.POL.CAMPO LIMPO PAULISTA, 1731/20/402 - DEL.POL.CAMPO LIMPO PAULISTA, 2162820 - DEL.POL.CAMPO LIMPO PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WALISSON DA SILVA DOS SANTOS

Réu Preso

Juiz de Direito: Marcel Nai Kai Lee

Vistos.

WALISSON DA SILVA DOS SANTOS, menor de vinte e um anos na data dos fatos, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Isto porque, no dia 5 de julho de 2020, por volta das 00h06, Comunidade São José II, na Rua Rio Solimões, 10 Jd. Santo Antônio, nesta cidade e Comarca, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, as substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, 52 (cinquenta e dois) eppendorfs contendo cocaína em sua forma petrificada - crack, peso bruto 70g, 48 (quarenta e oito) tubetes de cocaína, peso bruto 74g, 11(onze) vidrinhos contendo líquido transparente - lança-perfume peso 10l, 5 (cinco) tubetes com maconha e 17 (dezessete) invólucros de maconha, peso

bruto 73 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 7/8 e laudo de constatação de fls. 12/14 (fls. 78/80).

Preso em flagrante, o réu foi beneficiado com a liberdade provisória em audiência de custódia (fls. 47/48).

A denúncia foi recebida em 6 de agosto de 2020 (fls. 82/83).

Certidão criminal (fls. 90).

FA (fls. 91/93).

Laudo de exame químico-toxicológico (fls. 94/98 e 99/101).

Pedida a prisão preventiva pelo MP em razão de ser o réu procurado em outro estado (fls. 106/109).

Deferido o pedido de prisão preventiva (fls. 110 e 118).

Não localizado o réu para citação, foi deferida a citação por edital (fls. 133 e 134/135).

Cumprido o mandado de prisão em 30/05/2022 (fls. 145/147)

Em atenção ao disposto no art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal (com redação dada pela Lei nº 13.964/2019) e Comunicado nº 78/2020 da E.

Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo, a prisão preventiva do réu foi analisada e mantida em 31/05/22 (fls. 151/152).

Citado pessoalmente (fls. 159), o réu apresentou resposta escrita às fls. 165/167, por meio de advogado constituído (fls. 165/167).

Confirmado o recebimento da denúncia e indeferido o pedido de liberdade provisória do acusado (fls. 168).

Laudo químico-toxicológico do restante das drogas (fls. 193/195).

Em audiência de instrução (fls. 198/199), foi ouvida uma testemunha (fls. 200) e em seguida o réu foi interrogado (fls. 201). Em alegações apresentadas oralmente, o Ministério Público pediu a procedência da pretensão penal nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pediu a fixação das penas no grau mínimo, com a consideração da atenuante da confissão e causa de diminuição de pena (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06); por fim, que a pena privativa de liberdade seja substituída por restritiva de direito, que o regime fixado seja o aberto e a concessão do direito de recorrer em liberdade,

É o relatório. Fundamento e decido.

Com vênias ao esforço do combativo advogado, o pedido condenatório é procedente.

A materialidade do crime foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (fls. 5/6), auto de exibição e apreensão das drogas (fls. 7/8), auto de exibição e apreensão do dinheiro (fls. 9) e, em especial, pelos laudos de exame químico toxicológico, que atestaram positivo CLORETO DE METILENO/DICLOROMETANO (fls. 97/98); para TETRAHIDROCANABINOL (THC), princípio ativo da Cannabis sativa L, bem como COCAÍNA, em sua forma pura e como substância ativa do crack (fls. 193/195).

Da mesma forma, a autoria é inquestionável.

Leonardo Moreira Iorio, policial militar, declarou que estavam em patrulhamento, quando avistaram o réu com uma sacola nas mãos; ao ver a aproximação da viatura o réu correu mas foi alcançado pelo PM Joffre. Na sacola havia drogas. Não se recordou dos valores apreendidos. O réu confessou informalmente o tráfico e não ofereceu nenhuma resistência. Até então não conhecia o réu.

No sentido da credibilidade da palavra dos agentes de segurança pública:

“O valor de depoimento testemunhal de policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF – HC nº 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

E ainda:

“Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o

exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP – Rel. Min. Moura Ribeiro – j. 27.05.14; RHC 45.173/SP – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 26.05.14 e HC 109.105/SP – Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima – j. 23.02.10) (TJSP. Apelação 0021769-95.1998.8.26.0079. Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária. Relator: Ailton Vieira. Data do julgamento: 14/09/2016. Data de registro: 19/09/2016). Nossos os destaques.

Interrogado, o réu confessou a prática do crime, declarando que estava no local traficando por necessidade financeira e que possui um filho para criar. É seu primeiro processo criminal.

Logo, restou devidamente demonstrado que o réu estava traficando no local, ou seja, não se trata de condenação tão somente com base em confissão, mas sim que esta foi ratificada pela prova testemunhal.

Portanto, restando devidamente comprovadas a materialidade e autoria do crime, a responsabilização penal se impõe, na ausência de excludentes, visto que, o ônus de provar o alegado estado de necessidade pertencia à Defesa, que dele não se desincumbiu.

Passo a fixar as penas.

Na primeira fase de fixação das penas, em atenção às diretrizes do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade das drogas e ainda personalidade e conduta social do agente), preponderantes sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, visto que o delito ora em análise é tipificado em lei especial, aumento as penas em dois quartos (2/4), em razão da quantidade e diversidade de drogas encontradas (cinquenta e dois eppendorfs contendo cocaína em sua forma petrificada - CRACK, com peso bruto de 70g; quarenta e oito tubetes de COCAÍNA, com peso bruto 74g; onze vidrinhos contendo líquido transparente - LANÇA-PERFUME, com peso de 10lg; e cinco tubetes e dezessete invólucros de MACONHA, com peso bruto de 73 g.), bem como da natureza, notadamente cocaína e crack, de elevado potencial lesivo, que provoca a dependência do usuário em intervalo de tempo extremamente reduzido, que atingem o bem jurídico (saúde pública) de forma mais severa, elevando-as para sete anos e seis meses de reclusão e pagamento de setecentos e cinquenta dias-multa.

Na segunda fase, ante a presença das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, trago as penas aos patamares mínimos de cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa.

Na terceira fase, entendo que o réu não preenche os requisitos descritos no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, isto porque, além de não se tratar de direito subjetivo do acusado, mas de faculdade atribuída ao Julgador, para ajuste na dosimetria da pena, sempre tendo em conta o disposto no art. 42, a elevada quantidade e diversidade de drogas indica a dedicação do réu em atividade criminosa, afastando sua tentativa de dizer que era a primeira vez que praticou o

ilícito.

Ad argumentandum tantum, anoto que não há que se cogitar de bis in idem, visto que as razões que levaram ao aumento de pena na primeira fase e tipificadas no art. 42 de Lei de Drogas, não estão sendo usadas para um novo aumento, mas sim para negar a redução.

O valor unitário deverá ser o mínimo legal, em razão da ausência de elementos concretos sobre a situação econômica do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal que a Justiça Pública move contra WALISSON DA SILVA DOS SANTOS, menor de vinte e um anos na data dos fatos, já qualificado nos autos, para, com base no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, CONDENÁ-LO às penas de cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa, no valor unitário mínimo.

Com vênia a entendimentos em contrário, entendo inaplicável a Lei nº 12.736/12; isto porque o Magistrado, no momento da prolação da sentença, não possui elementos para a aplicação de eventual detração penal e progressão de regime penitenciário. Como cediço, não basta o mero abatimento na pena final do tempo de cumprimento de prisão cautelar; há que se ter em conta as imprescindíveis informações do estabelecimento penal quanto ao comportamento do acusado e folha de antecedentes. Por sinal, até mesmo a constitucionalidade da lei há que ser analisada de forma mais apurada, visto que, salvo melhor juízo, a alteração normativa ignora o princípio do Juiz Natural e até mesmo da individualização da pena.

Neste sentido, eis recente acórdão do TJSP: "Pena - Detração - Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade - Art. 387, § 2º, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 - Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3º e 59 do CP - Entendimento O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença". (TJSP. Apelação nº 0012399-50.2003.8.26.0198. Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal. Relator: Grassi Neto. Data do julgamento: 18/08/2016. Data de registro: 01/09/2016). Deixo de aplicar pena alternativa ou suspensão condicional da pena, por não cumprimento dos requisitos legais, objetivos e subjetivos.

Nos termos da Lei nº 8.072/90, em especial das circunstâncias desfavoráveis do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 e atento ao fato de que o tráfico de drogas fomenta uma série de outros delitos tais como homicídios, roubos, furtos etc., que tem destruído milhares de famílias e ainda que atinge seriamente o Sistema de Saúde do país que, progressivamente vem aumentando seus gastos com internações e tratamento de dependentes químicos, cumprirá o réu a pena privativa de liberdade inicialmente no regime FECHADO. Destaco que nenhum dos respeitáveis entendimentos do STJ e do STF foi sedimentado em Súmula Vinculante.

No sentido da correção de fixação de regime fechado para os crimes de tráfico de drogas: "O regime inicial de cumprimento de pena para os crimes de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu

tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto." (TSJP. Apelação nº 0010186-03.2015.8.26.0602. 1ª Câmara Criminal Extraordinária. Relator: Airton Vieira. Data do julgamento: 06/07/2016. Data de registro: 12/07/2016).

E ainda, convém destacar trecho do voto do Eminentíssimo Desembargador DAMIÃO COGAN, do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos da apelação nº 0000779-16.2016.8.26.0544, Quinta Câmara de Direito Criminal, J. em 21/09/2017: "O regime inicial fechado é o único adequado em face do Princípio da Suficiência Penal, mormente porque se trata de delito equiparado a hediondo, que enseja maior repressão e reprovação, por ser verdadeiro flagelo da sociedade hodiernamente. Anote-se que o regime aberto é incompatível com a infração de tráfico de drogas, que se tornou uma das grandes pragas modernas a atormentar a sociedade, mormente no Brasil, antes país de passagem da droga para o exterior, sendo hoje um dos países com grande número de traficantes, passando a droga a ser utilizada aqui. Assim, transformando-se o tráfico num dos verdadeiros cancrios da atualidade, envolvendo jovens e desagregando famílias, deve ele ser combatido com rigor, rigor este que só se encontra presente na imposição do regime fechado para o traficante. Ademais, não pode o julgador ter seu olhar voltado para as estrelas, mas deve ser homem do seu tempo, que não ignora que a leniência com o tráfico destrói famílias, jogando usuários e viciados na sarjeta, bem como incrementa roubos, latrocínios, furtos e homicídios."

Outrossim, com a mais necessária vênia, reitero que a decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal nos autos do HC 97.256/RS, consolidada pela Resolução nº 5 do Senado Federal, não possui força vinculante e muito menos afastou do Juiz a análise das circunstâncias concretas do caso.

Nesse sentido, a Colenda Quinta Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu recentemente:

"(...) a respeitabilíssima decisão do E. Supremo Tribunal Federal mencionada pela impetrante foi declarada incidentalmente. E, de qualquer forma, o reconhecimento do que se denominou "tráfico privilegiado" (e nem parece ser o caso) não obriga o estabelecimento desse ou daquele regime, o que vai ser fixado consoante as condições específicas do caso. De mais a mais, impossível apreciar, nesta fase, se o paciente preenche os requisitos do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Ainda que a conduta de tráfico privilegiado não fosse considerada hedionda, observo e insisto, isso não impediria a prisão preventiva ou garantiria ao réu o direito ao regime aberto. Restou demonstrado, conforme já consignado, a necessidade da prisão cautelar do paciente, diante da gravidade em concreto da conduta. Colocar o paciente, intimamente ligado ao tráfico em larga escala, reafirmo, coloca em risco concreto toda a sociedade" (TJSP. Habeas Corpus nº 2154869-28.2016.8.26.0000, Indaiatuba, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pinheiro Franco, j. 01/09.2016).

Em atenção ao disposto no art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal (com redação dada pela Lei nº 13.964/2019) e Comunicado nº 78/2020 da E.

Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo, mantenho a prisão preventiva do réu, agora com mais razão ante a sentença condenatória ora proferida.

O réu permaneceu preso durante o procedimento penal, em razão da presença dos requisitos e hipóteses autorizadoras de tal custódia, de tal sorte que não poderá apelar em liberdade, pois não houve qualquer alteração fática de tal quadro.

Destaco que a decisão por maioria de votos do Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC nº 104339, quanto à inconstitucionalidade de parte do art. 44 da Lei nº 11.343/2006 apenas se refere à regra que proíbe a liberdade provisória; ou seja, não importa na vedação da decretação da prisão preventiva, desde que presente seus requisitos e pressupostos, o que é o caso sub judice.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Quanto às custas processuais, condeno o réu no valor de 100 (cem) Ufesp's, nos termos do art. 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observado o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50, caso ele seja beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Nos termos do art. 63, §1º e 64 da Lei nº 11.343/06, decreto a perda em favor do Estado de valores e bens apreendidos em poder do acusado.

Após o trânsito em julgado desta sentença, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral com jurisdição sobre o domicílio eleitoral do condenado para suspensão de seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal (art. 18 da Res/CNJ 113/10). Dispensado o registro da sentença, nos termos do art. 72, §6º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Procedam-se as devidas anotações, comunicações e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Campo Limpo Paulista, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA